



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4015/2014/3/CA1

Paraná, 25 de agosto de 2.017.

Y VISTO: en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Mateo José BUSANICHE, Presidente; la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Vicepresidenta y el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Juez de Cámara Subrogante, en el Expte. N° FPA 4015/2014/3/CA1, caratulado: **"LEGAJO DE APELACIÓN DE VALDEZ, ANDRÉS MARTÍN; CARDOSO, NELIDA BERTA EN AUTOS VALDEZ, ANDRÉS MARTÍN; CARDOSO, NELIDA BERTA POR INFRACCION LEY 23.737"**, provenientes del Juzgado Federal N° 1 de Paraná, y;

DEL QUE RESULTA:

El Dr. Mateo José Busaniche, dijo:

Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de los imputados Andrés Martín Valdez y Nélide Berta Cardoso a fs. 11/19, contra la resolución obrante a fs. 1/10, en cuanto procesa a los nombrados por el delito de siembra o cultivo de plantas utilizables para producir estupefacientes, previsto y reprimido en el art. 5 inc. a) de la ley 23.737, en función del art. 45 del C.P. y de conformidad a los arts. 306, 308 y 311 del Cód. Proc. Penal. El recurso es concedido a fs. 20.

Fecha de firma: 25/08/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN



#30130843#186606321#20170825103044598

En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., de la que da cuenta el acta de fs. 38 y vta., compareciendo en la oportunidad el Sr. Fiscal General de Cámara, Dr. Ricardo C. M. Álvarez; y la Sra. Defensora Pública Coadyuvante, Dra. Mónica Mariela Nardi de Brouchy, en defensa de Andrés Martín Cardoso y Nélida Berta Cardozo; quedando los presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- a) Que, la Sra. Defensora Pública Coadyuvante sostiene que el auto de procesamiento que se recurre provoca un gravamen irreparable en atención a las erróneas consideraciones fácticas y de aplicación de la ley.

Reseña el devenir de las actuaciones, menciona los tóxicos que se secuestraran y adhiere a la motivación del recurso. Destaca que el Juez sólo mantiene la imputación por las dos plantas halladas en el patio. Alude a los dichos de Cardoso respecto de su enfermedad y su desconocimiento de la existencia de las plantas. Sostiene que se trata de una persona de 70 años, que no tiene vicios, que está medicada y respecto de la cual se ignora si efectivamente conocía la planta. Resalta que el





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4015/2014/3/CA1

informe médico revela que no es consumidora y que tiene 7 hijos pero que ninguno vive en ese domicilio, por lo que es ilegítimo presumir que podían conocer la existencia de planta y que podrían haber consumido. Concluye que no existe ningún elemento que permita acreditar que Cardoso tenía la disponibilidad del tóxico.

Cita el informe médico respecto de Valdez y menciona sus dichos. Destaca que hace 25 años que consume tóxicos y cuestiona que se tenga en cuenta tal circunstancia para desincriminarlo por el estupefaciente hallado en su habitación, y no respecto de las plantas secuestradas en el patio. Critica los argumentos de la resolución y efectúa consideraciones respecto del bien jurídico protegido por la norma. Cita jurisprudencia y estima que es insostenible que no se considere que era para su consumo personal.

Cuestiona la referencia a la cantidad de estupefaciente ya que sabido es que no indica el destino de la tenencia ya que cada sujeto consume en forma desigual. Evoca que las plantas se encontraban en su domicilio, no en un lugar público, que fueron halladas en virtud de una orden de allanamiento y que nadie más compartía la vivienda. Sostiene que la

Fecha de firma: 25/08/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN



#30130843#186606321#20170825103044598

correcta calificación es el cultivo atenuado previsto en la última parte del inciso a) de la ley 23.737.

Efectúa consideraciones respecto de la ultraactividad que exige la figura escogida por el magistrado y manifiesta que no comprobó el comercio en dicha vivienda, ni se secuestró ningún elemento. Solicita se decrete el sobreseimiento de la imputada Cardoso y respecto de Valdez, propicia se modifique la calificación jurídica atribuida por la figura prevista en el anteúltimo párrafo del art. 5 de la ley 23.737, es decir el cultivo de estupefacientes para consumo personal, y decrete la inconstitucionalidad por aplicación del fallo Arriola, o en su caso, la atipicidad de dicha conducta.

Menciona el procedimiento que diera inicio a las actuaciones y el tiempo de la instrucción. Cita las fechas de inicio de la causa y de la citación a indagatoria y destaca que han transcurrido más de dos años para el dictado del auto de procesamiento. Plantea también la prescripción de la acción penal.

b) A su turno, el Sr. Fiscal General alude a los agravios de la defensa. Analiza si resulta





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4015/2014/3/CA1

legítimo modificar la subsunción jurídica escogida por el Juez en el auto de procesamiento, cuál sería la correcta y qué incidencia tendría respecto del planteo de prescripción de la defensa.

Alude al inicio de la causa y reseña el hecho que se investiga, resaltando que la Fiscalía propició subsumir la conducta en la figura de cultivo atenuada, prevista en el art. 5 a) anteúltimo párrafo de la ley 23.737. Destaca que el juez imputa de forma genérica y acaba procesando por el cultivo agravado por las plantas y sobresee a los imputados por las semillas y las hojas secas incautadas. Menciona los dichos de Cardoso y refiere a inconsistencias en la indagatoria que sugiere se remuevan.

Destaca el informe médico de Valdez y en relación a Cardoso, indica que no basta con conocer, sino que se debe tener disponibilidad del tóxico. Reitera que el simple conocer no la convierte en coautora. Efectúa consideraciones respecto de la figura de cultivo destinado a consumo personal y las figuras de tráfico de estupefacientes. Estima que en el caso, se trató de un cultivo artesanal de dos plantas y que la calificación jurídica debe modificarse por un cultivo atenuado.

Fecha de firma: 25/08/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN



#30130843#186606321#20170825103044598

Agrega que resulta necesario reflexionar respecto de la prescripción pero no abre juicio al respecto porque estima que debe ser el juzgado quien decida la cuestión. Concluye que debería subsumirse el hecho en la figura de cultivo atenuada, prevista en el art. 5 inc. a) anteúltimo párrafo de la ley 23.737 y se disponga la formación del respectivo incidente en la instancia a-quo, a fin de que analice la posible prescripción de la acción penal.

II- Que, las actuaciones principales reconocen su inicio el 5 de abril de 2014, a las 17:45 hs. aproximadamente, en el domicilio sito en calle Concejal Carbone N°883 Barrio 25 de Mayo, de la ciudad de Gualaguay, provincia de Entre Ríos, habitada por Nélida Berta Cardozo y Valdez Andrés Martín, y en ocasión de dar cumplimiento a la orden de allanamiento n° 90/14 librada por el Sr. Juez de Garantías n°2 de Gualaguay, por parte de personal de la policía de Entre Ríos. Allí se constató la presencia de hojas de marihuana dentro del ropero emplazado en una de las habitaciones de la finca, y dentro de un frasco de vidrio en el lavadero de la vivienda, con un peso de 4,933 gramos. Asimismo, se verificó la siembra o cultivo de dos plantas de dicha especie vegetal, localizadas en el patio de la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4015/2014/3/CA1

finca; y la guarda de semillas utilizables para producir estupefacientes cuyo peso ascendía a 9 gramos, las que fueron habidas dentro de un lapicero, en uno de los dormitorios de la finca.

El 15/04/2014 el Sr. Juez de Garantías y Transición Nº2 se declaró incompetente y remitió las actuaciones al Sr. Juez a-quo. Instruidas las actuaciones, fueron indagados Cardoso y Valdez y el 30/12/2016 se decretó el sobreseimiento parcial de los nombrados por el delito de guarda de semillas utilizables para producir estupefacientes -art. 5 inc. c) de la ley 23.737-; respecto de Valdez su sobreseimiento por el delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal; y en relación a Cardoso su sobreseimiento por el delito previsto en el art. 14 de la ley 23.737. Asimismo, se procesó a ambos imputados por el delito de siembra o cultivo de plantas utilizables para producir estupefacientes -art. 5 inc. a) de la ley 23.737-. Contra esto último se alzó la defensa, dando lugar a esta instancia.

III- Que, corresponde, en primer lugar dar tratamiento a los agravios con relación al dictado de procesamiento de Nélida Berta Cardoso y por los cuales solicita se decrete su sobreseimiento.

Fecha de firma: 25/08/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN



#30130843#186606321#20170825103044598

Al respecto, cabe poner de resalto que corresponde señalar que las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fueras habidas las dos plantas de marihuana en el patio de la vivienda situada en calle Concejal Carbone N° 883 Barrio 25 de Mayo de la localidad de Gualeguay, en la que reside la imputada, permiten *-prima facie-* sostener la imputación realizada a ésta.

Abona tal conclusión, el resultado del allanamiento dispuesto en dicho domicilio, cuya acta da cuenta del hallazgo de las plantas (fs. 5/7 y su transcripción de fs. 8/9), todo lo cual se vio corroborado con los testimonios en sede judicial de los agentes Isaurralde y Dotta, y de los testigos Pérez y Valdez.

En tal sentido, la circunstancia en que las plantas en cuestión fueran habidas en el patio de la vivienda de la nombrada, da cuenta de la disponibilidad de Cardoso sobre éstas, encontrándose en su esfera de custodia, todo lo cual permite sostener el co-dominio del hecho que se le atribuye.

Por otro lado, las alegaciones de la imputada respecto del desconocimiento de la existencia de dicho cultivo, se encuentran desprovistas de elementos de convicción que permitan





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4015/2014/3/CA1

por el momento darle aquí favorable acogida, máxime si se tiene en cuenta el tamaño de las mismas -1,50 m. y 2,30 m de alto-.

Que, en cuanto a la tipicidad subjetiva, ello obsta -al menos por el momento- a su exclusión, lo cual se aduna con las relevantes circunstancias fácticas señaladas con anterioridad. Debe recordarse que es criterio reiterado de esta Alzada que "dado que las reglas de imputación del conocimiento operan siempre una vez que han sido fijadas las circunstancias objetivas que se consideren probadas, han de valorarse los hechos significativos que sirvan de base para imputar conocimientos al sujeto, partiendo de que existen reglas generales de experiencia sobre el conocimiento o desconocimiento ajeno" (cfr. L.S.Crim. 2004-I-149, entre otros).

En tal sentido, se ha reunido un cúmulo de elementos que permite mantener la imputación -con el grado de convicción propio de esta instancia- respecto de la nombrada, recordándose que el art. 306 C.P.P.N. no contiene la exigencia de que se acredite fehacientemente la comisión de un delito, sino que existan elementos de convicción suficientes sobre el mismo.

Fecha de firma: 25/08/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN



#30130843#186606321#20170825103044598

Por todo lo expuesto, corresponde en este punto rechazar el recurso de apelación interpuesto.

IV- a) Que, por otro lado, la defensa cuestiona la subsunción del hecho que efectuara el Sr. Juez a-quo, entendiendo que debió calificarse el hecho por la figura prevista en el art. 5 inc. a), anteúltimo párrafo, de la ley 23.737, es decir el cultivo para consumo personal, y decrete la inconstitucionalidad por aplicación del fallo Arriola, o en su caso, la atipicidad de dicha conducta.

b) Que, al respecto, este Cuerpo tiene reiteradamente sentado que en los recursos deducidos contra el auto de procesamiento la cuestión concerniente a la calificación de la conducta, atento a su provisoriedad, resulta -en principio- ajena a esta instancia.

Hemos sostenido que, "para ello, se atiende especialmente, a que... la cuestión es propia, en el caso, del llamado principio 'iura novit curia', dado que los hechos ... fueron comunicados siempre ... de un modo amplio, preservando su derecho de defensa, por lo que el progreso de la causa, permitirá, en su caso, que la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4015/2014/3/CA1

intimación sea rectificadora" (cfr. L.S.Crim. 2013-I-0431).

Sin perjuicio de ello, constituiría motivación suficiente para el tratamiento de la cuestión en esta instancia, si la posible revisión de la calificación jurídica pudiera tener incidencia en la modificación de una situación de privación de libertad o cuando su tratamiento pudiera dar lugar a la desvinculación definitiva del imputado de los hechos que se le reprochan, siempre que ello sea posible de realizarse en esta Alzada sin la necesidad de incorporar nuevos elementos de valoración a los ya existentes, ni que ello implique un análisis propio de la instancia de debate o juicio (cfr. voto de los Dres. Alonso y Busaniche en L.S.Crim. 2013-II-0797, entre otros).

Ello importa entonces, en este caso, exceptuar el principio general y dar tratamiento a los agravios esgrimidos por la defensa.

c) Sentado aquello, cabe destacar que la calificación escogida por el Sr. Juez a-quo ha sido cuestionada por la defensa, que propugna aquella que prevé la conducta de quien siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes, o materias primas, o elementos

Fecha de firma: 25/08/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN



#30130843#186606321#20170825103044598

destinados a su producción o fabricación, cuando por la escasa cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias, surja inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes para consumo personal.

En tal sentido, además de las circunstancias referidas al hallazgo de las plantas de cannabis sativa en poder de los imputados Cardoso y Valdez reflejadas en el acta de procedimiento, cabe tener en consideración que los informes médicos revelan que Cardoso no es adicta a ningún tipo de estupefaciente y con relación a Valdez se advierte *"la existencia de signología presuntiva del consumo de estupefacientes"* y que *"padece un trastorno inducido por sustancias tóxicas bajo la clínica de dependencia psíquica"* (cfr. fs. 100 y 126/127 vta. de los autos principales); por lo que luce atinado sostener que la tenencia del tóxico era para uso personal.

Por otro lado, la pericia química concluye que las plantas secuestradas eran cannabis sativa con un peso de 155,67 gr y una concentración de THC promedio de 1,62% (fs. 33/36 de los autos principales), por lo que puede razonablemente





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4015/2014/3/CA1

considerarse que se trataba de escasa cantidad, tal como lo exige la figura propuesta por la defensa.

Atento a todo lo expuesto, el accionar de los encausados Cardoso y Valdez corresponde que sea encuadrado en la figura prevista en el artículo 5 inc. a), anteúltimo párrafo, de la ley 23.737.

d) Que dicho ello y conforme a la calificación que se ha seleccionado para la conducta atribuida a Cardoso y Valdez, corresponde analizar si es posible ensayar una interpretación del art. 5 inc. a), anteúltimo párrafo, de la ley 23.737 compatible con la letra constitucional, en cuanto ésta consagra el principio de reserva en su art. 19.

Cabe destacar que nuestro Máximo Tribunal en el fallo "Arriola" resolvió la declaración de inconstitucionalidad del art. 14, apartado segundo de la ley 23.737, en cuanto incrimina la tenencia de estupefacientes para uso personal que se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros.

Argumentó también el Alto Tribunal que los consumidores de drogas, en especial cuando se transforman en adictos, son las víctimas más visibles -junto a sus familias- del flagelo del



narcotráfico; por lo cual, no parece irrazonable sostener que una respuesta punitiva del Estado al consumidor se traduzca en una revictimización y reitera la necesidad de combatir el tráfico de drogas, no a través de la persecución penal de sus propias víctimas -es decir los consumidores- sino de los distribuidores. Agregó, que si bien como principio, lo referente al mejor modo de perseguir el delito y cuáles son los bienes jurídicos que requieren mayor protección, constituyen cuestiones de política criminal propias de otras esferas del Estado, lo cierto es que allí se trataba de la impugnación de un sistema normativo que criminaliza conductas que -realizadas bajo determinadas circunstancias- no afectaban a un tercero y, por lo tanto están a resguardo del artículo 19 de la Constitución Nacional. Siguiendo ese razonamiento, entendió que el Congreso había sobrepasado las facultades que le otorgaba la Carta Magna.

Dichas razones serían enteramente aplicables a la figura que reprime el cultivo, la siembra, etc., cuando tales actividades, por la escasa cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias, estuvieran destinadas a obtener estupefacientes para consumo personal.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4015/2014/3/CA1

Que, la cuestión radica, entonces, en determinar si el material estupefaciente hallado, supuestamente cultivado con destino de consumo personal, ha puesto en peligro el bien jurídico protegido -salud pública- por el riesgo de trascendencia a terceros, atendiendo fundamentalmente al ámbito en el que se produjo el hallazgo y secuestro.

A la luz de éstos parámetros, cabe destacar que las dos plantas de cannabis sativa fueron halladas en el patio de la vivienda en la que habitaban únicamente Cardoso y Valdez, circunstancia que sólo pudo ser constatado como consecuencia de una orden de allanamiento dispuesta por la justicia provincial -cuyo objeto era el hallazgo de elementos que habrían sido objetos de un robo-, todo lo cual permite concluir que ha quedado bajo la esfera personal o íntima de los imputados.

En ese marco, con esos límites y conforme las circunstancias en que se produjo el hallazgo de las mismas, cabe concluir que dicho cultivo no trajo aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros, por lo que el hecho es asimilable al que diera lugar a la doctrina judicial sentada por la Corte Suprema de Justicia de la

Fecha de firma: 25/08/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN



#30130843#186606321#20170825103044598

Nación en los autos referidos.

Por lo expuesto corresponde por imperio de la autoridad institucional de las pautas del más alto cuerpo judicial de la República, declarar la inconstitucionalidad del art. 5 inc. a) anteúltimo párrafo de la ley 23.737, y en consecuencia sobreseer a Andrés Martín Valdez y Nélida Berta Cardoso (cfr. art. 336 C.P.P.P.N.).

V- Que, en atención a lo aquí resuelto, deviene inoficioso el tratamiento del resto de las cuestiones planteadas en las presentes.

La Dra. Cintia Graciela Gomez, dijo: I..., II..., III..., IV- Que sobre el punto, he de disentir con el voto precedente, ello pues, en el caso, la eventual mutación de la figura penal endilgada a los imputados carece de entidad suficiente para modificar la situación de hecho - libertad- en la que aquellos se encuentran.

En efecto, la circunstancia de que el sustrato fáctico fuera correctamente comunicado a los imputados (cfr. declaraciones indagatorias obrantes en Sistema LEX 100), viabiliza la eventual revisión de la calificación de la intervención punible, en el momento procesal correspondiente, salvaguardando el derecho de defensa y





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4015/2014/3/CA1

paralelamente, asegurando el principio de congruencia.

Por estos fundamentos, propongo rechazar el recurso instado sobre el punto y confirmar la resolución apelada.

El **Dr. Daniel Edgardo Alonso**, dijo: Que adhiere a la solución propuesta por el Dr. Busaniche.

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, por mayoría, **SE RESUELVE:**

I.- Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la defensa y en consecuencia, al cambio de calificación solicitado, encuadrando el accionar de Andrés Martín Valdez y Nélide Berta Cardoso en la figura prevista por el artículo 5 inc. a) anteúltimo párrafo de la ley 23.737.

II.- Declarar la inconstitucionalidad del art. 5 inc. a), anteúltimo párrafo, de la ley 23.737.

III.- Dictar el sobreseimiento de Andrés Martín Valdez y Nélide Berta Cardoso, cuyos demás datos de identidad obran en autos, en orden al delito de siembra o cultivo de plantas utilizabales para producir estupefacientes para consumo personal

Fecha de firma: 25/08/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN



#30130843#186606321#20170825103044598

(art. 5 inc. a) anteúltimo párrafo de la Ley 23.737), de conformidad con lo prescripto por el artículo 336 y ccdtes. del C.P.P.N., haciendo expresa mención que la formación del presente sumario no afecta el buen nombre y honor del que los nombrados gozaren.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

Se deja constancia que la Dra. Cintia Graciela Gomez estuvo presente en la deliberación, no suscribiendo la presente de conformidad a lo establecido en el art. 399, 2° párr. del C.P.P.N. y al art. 109 del R.J.N.

DANIEL EDGARDO ALONSO

MATEO JOSÉ BUSANICHE

ANTE MI

BERNARDO JOSÉ ARANGUREN
SECRETARIO DE CÁMARA

